



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, e nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile riassunta di primo grado iscritta al n. r.g. **66837/2022**, avente ad **oggetto**:
Azione di accertamento dell'usucapione ed altro, vertente

TRA

Parte_1, nata a Roma il 18/06/1964, C.F.: **C.F._1** e
Parte_2, nato a Villa Verde (OR) il 26/01/1965, C.F.: **C.F._2** entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Mecenate n.20, presso l'avv. Margherita Tribioli (C.F.: **C.F._3**) che li rappresenta e difende giusta procura del 24.01.2022 apposta in calce all'atto di citazione del 25.01.2022 precedentemente notificato in data 28.01.2022/01.02.2022

ATTORI

NONCHÈ

Parte_2, nato a Villa Verde (OR) il 26/01/1965, C.F.: **C.F._2** e
Parte_3, nata a Roma il 5/10/1990, CF **C.F._4** entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Mecenate n.20, presso l'Avv. Margherita Tribioli (C.F.: **C.F._3**) giusta procura in atti quali eredi di **Persona_1**

INTERVENUTI VOLONTARI

E

Controparte_1 (C.F. **C.F._5**), nato a Borgorose (RI) il 30.6.1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lanatà (C.F. **C.F._6** – fax 0681151127 – **Email_1**) nonché dall'Avv. Vincenzo D'Avino (C.F. **C.F._7** - **Email_2** - fax 081.5106290) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via E. Monaci, 13, giusta procura in calce alla comparsa

CONVENUTO

E

Controparte_2

CONVENUTI CONTUMACI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

CONCLUSIONI

Come in atti.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132 E 281 QUINQUIES C.P.C.**

I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. I sigg.ri Parte_1, nata a Roma il 18/06/1964, C.F.: C.F._1 e Parte_2, nato a Villa Verde (OR) il 26/01/1965, C.F.: C.F._2 con atto notificato in data 31.7.2022 hanno citato in riassunzione Controparte_1 E Controparte_2 deceduta in 10.1.2022 EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma, per l'udienza del 16.2.2023, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta, per i motivi esposti in narrativa,

previo accertamento anche ex officio ed incidenter tantum della nullità, per le causali esposte nelle premesse, del suddetto atto pubblico di divisione di comunione, quale atto di provenienza, rogitato dal notaio Persona_2 Rep. 22500/17098 in data 26/11/2009,

accertare e dichiarare, in virtù di un utile possesso, l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, anche in forma cd. abbreviata, da parte degli attori, Sigg.ri Parte_1 [...] e Parte_2, dell'appartamento interno 5 di cui al suddetto atto pubblico di compravendita per notar Persona_3, Rep. 100105, così ivi descritto: "porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I e precisamente: appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 5, composto di due camere ed accessori, con annessa terrazza a livello, confinante con: vano scala, proprietà Scancelli o aventi causa per due lati. Detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 665, Particella 161, subalterno 511 e Particella 614, Sub 508 graffate -Via Prenestina n. 1204/I, piano 1, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 488,05". Con ogni conseguente statuizione e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nonché IVA e CPA”.

A tal riguardo hanno evidenziato che, con precedente atto di citazione notificato ma non iscritto a ruolo, avevano esposto e dedotto in fatto ed in diritto:

<< IN FATTO:

A) che, con atto pubblico del notaio dott. Persona_3 di Roma, Rep. 100105, stipulato il giorno 12/07/2010 (DOC 2), registrato a Roma il 22/07/2010 al numero 18902/1T e trascritto a Roma il 23/07/2010 numero particolare 53147 –numero generale 92261 di formalità, i coniugi Sigg.ri Parte_1 e Parte_2 acquistavano dai coniugi Sigg.ri Controparte_1 e CP_2 [...], per il prezzo di Euro 220.000,00, interamente corrisposto, saldato e quietanzato alla sottoscrizione del rogito (vedasi all'articolo 3 del contratto), la proprietà della "porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I e precisamente: appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 5, composto di due camere ed accessori, con annessa terrazza a livello, confinante con: vano scala, proprietà CP_1 o aventi causa per due lati. Detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 665, Particella 161, subalterno 511 e Particella 614, Sub 508 graffate -Via Prenestina n. 1204/I, piano 1, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 488,05";

B) che, nel suddetto atto pubblico di compravendita, la sunnominata parte venditrice dichiarava e garantiva (all'articolo 4 del contratto) che "quanto alienato con il presente atto è di sua piena proprietà per essere pervenuto per acquisto fattone, unitamente ai signori Persona_4 e Controparte_3, da Controparte_4 nato... , con atto autenticato nelle firme dal notaio Per_5 [...] di Roma in data 21 ottobre 1980 Rep. 1811/129 registrato a Roma il 7 novembre 1980 al n. 9622 serie 2 e trascritto a Roma il giorno 11 novembre 1980 al n. 57631 di formalità e successivo atto di divisione a rogito del notaio Persona_2 di Roma in data 26 novembre 2009 Rep. 22500/17098 debitamente registrato e trascritto a Roma il 21 dicembre 2009 al n. 92692 di formalità" (atto di provenienza: DOC 3);

C) che il giorno 12/07/2010, ossia dalla data del suddetto contratto di compravendita immobiliare (vedasi all'articolo 5 del contratto), gli acquirenti Sigg.ri [redacted] Parte_1 e [redacted] Pt_2 entravano in possesso dell'appartamento sopra descritto e da tale data lo hanno posseduto in modo continuativo, ininterrotto, pacifico ed esclusivo;

D) che, successivamente, con nota "protocollo UCE 2014/3278 del 17/01/2014" (DOC 4), pervenuta agli attuali attori in data 11/02/2014, [redacted] Controparte_5 comunicava "il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n.0/579861 sot.0, presentata dalla sig.ra CP_2 [redacted], relativamente alla realizzazione di un'unità residenziale distinta con int.5, di mq.62,00 di s.r.e un volume dichiarato di mc. 192,20, in VIA PRENESTINA 1204/I-00132 Roma", precisando che per lo stesso fabbricato "sono state presentate altre sedici pratiche...per una nuova volumetria complessiva, compresa la domanda in oggetto, di mc 2.864,40(2264,40 metri cubi in esubero rispetto ai 600 previsti per legge)". Risulta applicata la previsione normativa contenuta nell'art. 2, lett. b n.2 L.R. n.12/2004-"opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale" (l'applicazione di tale previsione normativa è anche valutabile come la più favorevole, stante il plafond di 300 mc per singola domanda di titolo abilitativo edilizio e stante la condizione che non venga superato, "nel suo complesso", il limite quantitativo di 600 mc.). Quindi, a seguito di detta comunicazione comunale gli attuali attori venivano a conoscenza delle seguenti circostanze: l'esistenza, in realtà, di ulteriori 16 domande di condono edilizio (DOC 5), tutte non dichiarate dai venditori nel suddetto rogito di compravendita per notar [redacted] Persona_6 . 100105 del 12/07/2010, tra le quali, in particolare, anche quella numero 579861 del 10 dicembre 2004 (DOC 6), di riferimento dell'appartamento interno 5 compravenduto; il fabbricato, di cui l'appartamento compravenduto è parte, era stato in realtà realizzato con ben 2264,40 metri cubi in esubero rispetto ai 600 previsti per legge (vedasi l'art. 2 co.1 lett. b della L. Rg. Lazio n. 12/2004).

E) Che con sentenza n.14605/2017 (DOC 7), pubblicata il 18/07/2017, emessa nella causa civile R.G. n. 45256/2014, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Decima Civile, accertava i "fatti reato di cui agli artt. 483 e 640 c.p." (reati istantanei: falso in atto pubblico e truffa contrattuale) ravvisati nella condotta dei venditori sigg.ri [redacted] Controparte_1 e [redacted] Controparte_2 e dichiarava "la nullità del contratto di compravendita del 12.7.2010, a rogito del notaio [redacted] Persona_3 , rep. n. 100105, racc. n. 17678, relativo all'immobile facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I, posto al primo piano int. 5". La suddetta sentenza è motivata dall'accertata edificazione abusiva (da valutarsi ex art. 2 co.1 lett. b della L. Rg. Lazio n. 12/2004), avvenuta negli anni '90 del secolo scorso, dei due piani residenziali del fabbricato di cui è parte l'appartamento de quo e dal comportamento, consapevolmente omissivo e reticente dei venditori, riguardo allo "stato effettivo del procedimento di sanatoria dell'immobile in questione, così come dell'impossibilità di sanarlo" (v. a pagina 10 della sentenza). La suddetta sentenza del Tribunale di Roma veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n.4675/2021 (DOC 8);

F) che, quale ulteriore circostanza taciuta dai venditori al momento del rogito, appare rilevante, per i dati contenuti, anche l'emersa sentenza penale di condanna irrevocabile n. 3251/2002 (DOC 9), emessa il 13/02/2002 dal Tribunale di Roma a definizione ex art.444 c.p.p. (su istanza personale degli imputati) del processo penale n. 64143/1999 R.G.N.R. a carico di [redacted] Parte_4 dichiarati colpevoli "per avere in concorso tra loro abusivamente realizzato le opere edili sottoindicate in assenza della concessione edilizia", ossia consistenti nella costruzione del primo e del secondo piano (di cui è parte l'appartamento int. 5 in questione) del fabbricato sito in Roma, via Prenestina1204/I.

IN DIRITTO:

1. L'entrata in possesso dell'appartamento di cui si tratta da parte degli attuali attori è avvenuta il **12/07/2010**, all'atto della stipula del suddetto rogito di compravendita per notar [redacted] Per_3 , Rep. 100105, trascritto il 23/07/2010. Gli stessi hanno sempre continuato, uti domini a

disporre dell'appartamento de quo, esercitandovi pubblicamente ed in modo esclusivo una signoria di fatto corrispondente al possesso di cui all'art. 1140, co. 1, c.c., con animus rem sibi habendi;

2. al caso di specie va applicata la norma dell'art. 1142 c.c.: **“il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”** (principio della presunzione del possesso intermedio);

3. è altresì applicabile l'istituto giuridico della cd. **accessione nel possesso**, come previsto dal secondo comma dell'art. 1146 c.c., il quale consente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria e, quindi, permette di conteggiare ai fini dell'usucapione periodi di tempo pregressi a quello di decorrenza del nuovo possesso sul bene. Nel caso di specie, il possesso "unibile" ai sensi di detta norma è esattamente quello dei sunnominati venditori, i coniugi Sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2 ;

4. la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “l'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà alla legge urbanistica” (Cass. 19/12/2012 n.23452) e che “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.” (Cass. 18/02/2013 n. 3979);

5. l'art. 40, comma 2, Legge n. 47/1985 e l'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 non trovano applicazione per gli acquisti della proprietà a titolo originario e, dunque, **non riguardano l'usucapione**. La normativa in discorso è chiara nel presupporre, come atto d'acquisto della proprietà di un'unità immobiliare (o come atto costitutivo di un diritto reale su di essa), un negozio giuridico frutto di autonomia negoziale. Sono espressamente fatti salvi i trasferimenti mortis causa, mentre non sono fatte salve le **divisioni di comunioni**;

6. nello specifico, mettendo a confronto le dichiarazioni riguardanti la conformità alla normativa urbanistica ed il titolo abilitativo rese dai coniugi Sigg.ri Controparte_1 e CP_2 [...], quale parte venditrice, nell'atto pubblico di compravendita del notaio dott. Persona_3 , Rep. 100105, in data **12/07/2010**(DOC 2), e le stesse dichiarazioni rese dai costruttori, i coniugi Sigg.ri Persona_4 e Controparte_3 ed i coniugi Sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2 , nell'atto pubblico di divisione della comunione in essere tra di loro, quale atto di provenienza, rogitato dal notaio Persona_2 Rep. 22500/17098 in data **26/11/2009**(DOC 3), emerge che il tenore di esse è identico. Entrambe le attestazioni sono **reticenti e non veritiere** su dati assolutamente rilevanti che i sunnominati venditori-costruttori non potevano non conoscere. L'indicazione dei dati è parziale e le domande di sanatoria indicate non corrispondono all'entità degli abusi edilizi commessi. La prova, riguardo al suddetto rogito di compravendita, è costituita dalla suddetta sentenza di nullità n.14605/2017 (DOC 7), la quale, nel contempo, per l'accertamento in essa contenuto, permette di riscontrare nel suddetto atto di divisione a rogito del notaio Per_2 (atto di provenienza) la stessa causa di nullità, rilevabile nel presente giudizio anche ex officio e con accertamento incidenter tantum, così come chiedono gli attuali attori;

7. per di più, in entrambi i suddetti atti pubblici (per notar Persona_3 , Rep. 100105, in data **12/07/2010** e per notar Persona_2 Rep. 22500/17098 in data **26/11/2009**) i sunnominati venditori-costruttori hanno taciuto anche il dato, innegabilmente rilevante, costituito dalla suindicata sentenza penale n.3251/2002 di condanna per abusivismo edilizio contenente l'**ordine di demolizione** delle suddette opere abusive dagli stessi realizzate; sentenza penale emessa, si badi bene, su domanda di patteggiamento riservata espressamente all'imputato e che, quindi, gli stessi venditori-costruttori non potevano non conoscere;

8. in materia di atti di trasferimento di immobili abusivi, con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, da ultimo, espresso la teoria della **nullità "testuale"**, a rivisitazione critica dell'orientamento giurisprudenziale al quale, in precedenza, erano pervenute le Sezioni Semplici con le sentenze n. 23591/2013, n.28194/2013 e n.25811/2014 (in tema di

nullità di compravendita immobiliare per illiceità dell'oggetto), in cui era stato affermato **"il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica"** ed a superamento, in parte, anche della teoria della cd. nullità formale, pure richiamata. Con la suddetta sentenza n. 8230 del 22/03/2019 le Sezioni Unite hanno stabilito: **"il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera; (...) -Se ciò è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale, secondo quanto ritenuto da parte della giurisprudenza sopra richiamata ai §§ 5.1 e 5.2. che va in parte qua superata, essa rileva piuttosto, come pure affermato in altre decisioni adesive alla teoria formale e sottolineato da un'accorta dottrina, quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile"**(v. pagg.21-22 della sentenza n. 8230/2019); **"La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale" (v. pag.26 della citata sentenza);**

9. inoltre, è principio ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr: Cass. Penale n. 11628/2012) in materia di trasferimenti immobiliari che a carico del venditore, al momento del rogito, sussiste **l'obbligo giuridico di dire la verità**("preordinato alla tutela d'interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà")in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione ed alla sua conformità alla normativa urbanistica;

10. pertanto, nella fattispecie in questione, stante l'indubbia nullità anche dell'atto di provenienza costituito dal rogito di divisione per notar Persona_2 Rep. 22500/17098 in data **26/11/2009** e visto che, di conseguenza, **l'appartamento interno 5** di cui si tratta non era di proprietà esclusiva dei venditori, i coniugi sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2, è ravvisabile la c.d. usucapione abbreviata prevista dall'art. 1159 c.c. con riferimento all'acquisto a non domino. Gli attuali attori, i coniugi Sigg.ri Parte_1 e Parte_2, hanno acquistato in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo all'acquisto. Dunque, nel caso di specie l'usucapione è maturata in dieci anni, termine decorrente dal 23/07/2010, giorno in cui è avvenuta la trascrizione del suddetto atto pubblico di compravendita per notar Persona_3, Rep. 100105, stipulato il 12/07/2010;

11. riguardo ai diritti cosiddetti autodeterminati, ossia individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene che ne costituisce l'oggetto), occorre aggiungere che tali diritti conservano la loro identità qualunque sia il fatto genetico sul quale si fondano e rispetto agli stessi, pertanto, la causa petendi non assume efficacia individuatrice (v.: Cass. 05/10/2009 n. 21257; Cass. 17/07/2007 n. 15915; Cass. 13/02/2007 n. 3089)>>

Instauratosi il contraddittorio, rispetto all'udienza fissata in citazione del **16 febbraio 2023, differita con decreto del 10.11.2022 alla data** dell'otto marzo 2023, si è costituito con comparsa contenente domanda riconvenzionale in data **16.2.2023** il Sig. Controparte_1 rappresentando in fatto ed in diritto che:

- nel luglio 2010 allorquando i Sigg.ri Parte_1 e Pt_2 hanno acquistato dai coniugi Sigg.ri CP_1 e Controparte_2 un appartamento facente parte del più ampio fabbricato sito in Roma alla Via Prenestina n. 1204/I, giusto contratto di compravendita del 12.7.2010 (doc. 2 di controparte);

- prima di tale contratto gli odierni convenuti avevano acquistato la proprietà di detto bene a seguito di atto di divisione della comunione (con i Sigg.ri **Persona_4** ed **Controparte_3** Rep. 22500/17098 del 26.11.2009 (doc. 3 di controparte);

- dopo aver acquistato la proprietà dell'immobile, gli odierni attori hanno ricevuto nel gennaio 2014 da **CP_5** un preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/579861, relativa all'appartamento acquistato nel 2010 (doc. 4 di controparte); con tale provvedimento, ed in seguito ad ulteriori approfondimenti, questi sono venuti a conoscenza della natura abusiva dell'appartamento e della pendenza di una serie di domande di condono sul complessivo fabbricato, nessuna delle quali sarebbe mai stata menzionata nell'atto di compravendita.

3. Per tale motivo i Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** hanno adito Codesto Ecc.mo Tribunale (R.G. n. 45256/2014) al fine di ottenere un provvedimento dichiarativo della nullità del contratto di compravendita stipulato il 12.7.2010, nonché la restituzione di tutto quanto versato a titolo di corrispettivo di compravendita.

4. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 14605/2017 (doc. 7 di controparte), che ha accertato la nullità dell'atto di compravendita; appellata innanzi alla Corte d'Appello di Roma, la decisione è stata confermata con sentenza n. 4675/2021, ora passata in giudicato (doc. 8 di controparte).

5. Dopo aver ottenuto la nullità dell'atto di compravendita e la restituzione di quanto in quella sede corrisposto, i Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** hanno nuovamente adito Codesto Ecc.mo Tribunale con il precipuo scopo di far accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'appartamento di Via Prenestina; in particolare, con l'atto di citazione hanno chiesto "previo accertamento anche ex officio ed incidenter tantum della nullità, per le causali esposte nelle premesse, del suddetto atto pubblico di divisione di comunione, quale atto di provenienza, rogitato dal notaio **Persona_2** Rep. 22500/17098 in data 26/11/2009, accertare e dichiarare, in virtù di un utile possesso, l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, anche in forma ed. abbreviata, da parte degli attori, Sigg.ri **Parte_1** e **Parte_2**, dell'appartamento interno 5 di cui al suddetto atto pubblico di compravendita per notar **Persona_3**, Rep. 100105, così ivi descritto: "porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I e precisamente: appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 5, composto di due camere ed accessori, con annessa terrazza a livello, confinante con: vano scala, proprietà Scancella o aventi causa per due lati. Detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 665, Particella 161, subalterno 511 e Particella 614, Sub 508 graffate - Via Prenestina n. 1204/I, piano 1, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 488,05". Con ogni conseguente statuizione e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nonché IVA e CPA" (doc. 1);

- l'avversa domanda è inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondato. A fronte di una compravendita immobiliare, l'attore ha innanzitutto chiesto che il relativo atto pubblico venisse dichiarato nullo per via della sussistenza di gravi irregolarità edilizie nell'immobile, manifestando così una chiara volontà di interrompere ogni legame anche con il bene compravenduto e, in pratica, di disfarsi dello stesso: significativo in tal senso il fatto che, dopo aver ricevuto la comunicazione preliminare di preavviso di rigetto della domanda di condono, parte attrice non abbia avviato alcuna iniziativa per dimostrare la regolarità edilizia dell'immobile, né tantomeno abbia contestato giudizialmente tale attività amministrativa; altrettanto significativo, il fatto che parte attrice non abbia contestato un inadempimento al venditore, invocando una riduzione del prezzo ovvero un risarcimento del danno;

- al contrario i Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** si sono concentrati unicamente sulla nullità radicale dell'atto di compravendita "restituendo" l'immobile al proprietario e chiedendo allo stesso

la restituzione integrale del prezzo, atteso che le irregolarità edilizie da loro riscontrate invalidavano completamente l'operazione negoziale;

- raggiunto tale scopo con la sentenza del Tribunale di Roma n. 14605/2017 (confermata con sentenza della Corte di Appello n. 4675/2021) l'immobile non è stato mai rilasciato, è l'attore ha agito - nella presente sede - chiedendo l'acquisto per usucapione dell'appartamento, manifestando così improvvisamente un rinnovato interesse per l'immobile. Dunque, se prima gli attori volevano chiudere ogni rapporto con l'immobile per via delle sue irregolarità edilizie, insistendo per la nullità del contratto e la restituzione del prezzo, ora ambiscono a riacquisire la proprietà dello stesso ricorrendo allo strumento dell'usucapione, ritenendo evidentemente marginali le irregolarità che avevano giustificato la loro precedente azione di nullità. Il che lascia emergere molte perplessità sul vero interesse sotteso alla presente azione, sulla sua legittimità e sulla sua meritevolezza in sede giudiziale;

- l'azione è evidentemente improcedibile per la dichiarazione di nullità dell'atto di divisione del 2009 per incompletezza del contraddittorio e per difetto di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.

Sulla scorta di tali premesse il Sig. **Controparte_1** ha chiesto: "Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, alla luce di tutto quanto innanzi argomentato, con ogni più ampia riserva:

in via principale,

- dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto sia la domanda, avanzata incidenter tantum, di accertamento della nullità dell'atto pubblico di divisione del 26.11.2009 Rep. 22500/17098, sia la domanda di acquisto della proprietà per usucapione dell'appartamento Via Prenestina n. 1204/I, censito catastalmente al Foglio 665, p.lla 161, sub. 551 e p.lla 614, sub. 508 graffate, sia, infine, tutto quanto ex adverso domandato nell'atto introduttivo del presente giudizio;

in via riconvenzionale,

- accertare, per quanto occorrer possa l'occupazione sine titolo da parte dei Sigg.ri **Parte_1 e **Pt_2**, dell'appartamento di Via Prenestina n. 1204/I, censito catastalmente al Foglio 665, p.lla 161, sub. 551 e p.lla 614, sub. 508 graffate e, per l'effetto, condannarli a liberare il predetto immobile da persone e cose ed a consegnarlo al sig. **CP_1** ;**

- ancora, in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri **Parte_1 e **Pt_2** al pagamento a favore del Sig. **CP_1** a titolo di risarcimento danno da occupazione sine titolo, come sopra meglio specificata, nonché a titolo di indennizzo per l'utilizzazione dell'immobile dal giugno 2010 al luglio 2021, come anche sopra meglio specificato, per una somma totale di € 79.012,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a cui devono aggiungersi le ulteriori somme per la detenzione dell'immobile fino al giorno dell'effettiva liberazione, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU ovvero in via equitativa;**

- ancora, sempre in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri **Parte_1 e **Pt_2** al risarcimento del danno a favore del sig. **CP_1** per il deterioramento dell'immobile, quantificato in € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU".**

Con comparsa di intervento volontario, il Sig. **Parte_2**, già parte istante nel presente procedimento, nonché la figlia sig.ra **Parte_3** si sono costituiti in giudizio nella loro qualità di eredi della Sig.ra **Parte_1** deceduta nelle more, ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 e 302 c.p.c. insistendo per l'integrale accoglimento della domanda giudiziale come proposta con l'atto introduttivo.

Espletata la mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti con allegazione ai rispettivi fascicoli, rigettate le richieste istruttorie, all'udienza dell'otto maggio 2024 la causa è stata trattenuta a sentenza ordinaria con

concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

III. In termini generali, appare opportuno premettere che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad autorità giudiziaria munita di iurisdictio) e validità o perseguibilità del processo (competenza giudiziale, capacità-legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) sono i requisiti che debbono sussistere, prima della proposizione della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito.

Il codice di rito all'art. 75, stabilisce che «sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere»; la capacità processuale (denominata anche legittimazione processuale o capacità di stare in giudizio) consiste nell'idoneità a proporre e a ricevere validamente la domanda e a compiere gli atti del processo. È il riflesso della capacità di agire di diritto sostanziale (art. 2 c.c.) e si acquista con il raggiungimento della maggiore età, tranne nei casi in cui al minore sia concessa una speciale capacità. La capacità di essere parte, ossia l'idoneità alla titolarità di posizioni giuridiche processuali, spetta a ogni persona fisica e giuridica, venendo a coincidere con la capacità giuridica di diritto sostanziale. Le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti possono stare in giudizio solo se «rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la loro capacità» (art. 75, co. 2, c.p.c.), giacché la legge individua nei rappresentanti legali – secondo le regole di diritto sostanziale – i soggetti che hanno il potere di stare in giudizio in rappresentanza di chi è privo della capacità di agire. Le persone giuridiche, rispetto alle quali si pone la questione dell'individuazione del rappresentante organico, devono stare in giudizio «per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge» o del proprio statuto (art. 75, co. 3, c.p.c.). La capacità processuale è un presupposto del processo, la cui mancanza impedisce al giudice di decidere la causa nel merito, arrestando il processo con una pronuncia di rito. Il giudice deve verificare, anche d'ufficio, il rispetto delle disposizioni in materia di capacità processuale e se ricorre un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti un termine per la sanatoria del vizio (art. 182 c.p.c.).

Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, dall'interesse ad agire e dalla legittimazione ad agire ed a resistere) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, sulla scorta della prospettazione, della capacità/legittimazione processuale e legittimazione ad causam della parte convenuta determina una pronuncia, in rito, sul processo che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci e di validità della domanda giudiziale.

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). E' ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. mentre non attiene alla legittimazione ma al merito della lite la questione relativa alla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (v. ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756 conf. a Cass. 5.11.1997, n. 10843).

Ne consegue che trattasi di questione di legitimatio ad causam nel solo caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio.

E' stata in tal senso superata la tesi della Cass. Civ. sez. III, sent. 4796 del 6.3.2006 secondo cui: *"La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria da sinistro stradale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto - malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame - al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, costituito dall'essere la convenuta proprietaria o meno dell'autovettura coinvolta nel sinistro)." (v. in senso conforme Cass. Civ., n. 2091 del 2012).*

Le S.U. della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2915 del 2016, hanno rinsaldato l'orientamento, antecedente al 2006, secondo cui: *"la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto"*.

Segnatamente le S.U. civili componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno ribadito i seguenti principi giurisprudenziali:

a) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ; b) cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa; c) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; d) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa; non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto; tale difesa può essere proposta in ogni fase del giudizio; a sua volta in giudizio può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; e) - la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio; f) il convenuto costituendosi tardivamente, accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto.

Invero la titolarità del diritto fatto valer in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene, quindi, alla fondatezza della stessa ed al merito della lis.

Gli elementi costitutivi – precisano le S.U.- possono consistere in meri fatti (ad esempio, per invocare giudizialmente il riconoscimento di una pensione d'inabilità, bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli) od in fatti-diritto (nella controversia all'attenzione della Suprema Corte, il diritto oggetto della domanda era il risarcimento del danno subito da un immobile e, tra gli elementi costitutivi della domanda, vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno, quindi, la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali, - il danno, il nesso di causalità - anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato: diritto reale che non è il diritto oggetto della domanda, cioè della tutela giudiziaria, ma ne è un suo elemento costitutivo).

Ora chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad affermarne la sussistenza ma deve allegare che quel diritto gli appartiene: deve dimostrare, cioè, che vi sono ragioni giuridiche che collegano quest'ultimo alla sua persona, sicché, sul piano dell'onere probatorio, giusta la ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.

In definitiva chi promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva dello stesso (ai fini della legittimazione ad agire), e, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Il convenuto, invece, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla, così esercitando una mera difesa.

Le Sezioni Unite hanno ricordato, sul punto, che le difese sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda; che esse possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore; che queste ultime potranno, a loro volta, riguardare prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure la contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto; che il codice civile, all'art. 2697, comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine eccezione, e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi che ne costituiscono l'oggetto a carico del convenuto.

All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle eccezioni in senso stretto che presenta un regime giuridico peculiare, a tal fine, rilevando la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, comma 2, c.p.c.). Sul piano pratico, la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio.

In definitiva, la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente, alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c.. È vero, infatti, che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.

In altri termini, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Tuttavia, - hanno proseguito le Sezioni Unite - la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.

Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.

Può poi accadere che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto: anche in questo caso la prova, il cui onere è a carico dell'attore, può dirsi raggiunta, né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto.

Più complessa è, invece, la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, comma 1, c.p.c.) ed "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, comma 1, c.p.c.).

Il silenzio - ha rimarcato il collegio - è cosa diversa dal riconoscimento (espreso, implicito o indiretto), sicché la non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto.

In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

Diversa, infine, è la considerazione del silenzio quando la parte non si sia costituita in giudizio. Invero, l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il principio di non contestazione, quindi, non si estende alla parte che sia rimasta contumace: la contumacia, infatti, esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti. In particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio). Costituendosi tardivamente, peraltro, il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte (ciò che è accaduto nel caso in esame).

Applicando siffatti principi al caso in esame, i coniugi Parte_1 ed Parte_2 hanno agito in proprio, quali contitolari del diritto controverso, azionato con la domanda di usucapione notificata ai controinteressati e non iscritta a ruolo e con la notifica dell'atto di citazione in riassunzione (v. art. 39 c.p.c. secondo cui la pendenza della lite e la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso).

Nondimeno, in data 16.7.2022 la signora Parte_1 è deceduta e sono intervenuti volontariamente nel giudizio, in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., quali coeredi, CP_1 e Parte_3.

Ex art. 110 c.p.c. quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. È in capo al successore universale che incombe l'onere di provare la propria qualità, in modo da poter giustificare la propria legittimazione ad agire o a contraddire; tuttavia, occorre precisare che il suddetto onere probatorio sorge soltanto qualora la controparte contesti in maniera specifica detta qualifica (nel caso di morte della persona fisica tale prova deve essere fornita attraverso la produzione del certificato di morte dell'autore e della denuncia di successione).

In tema di *legitimatio ad causam*, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la

produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024; v. massime precedenti n. 6745 del 2018)

Nella fattispecie, non è contestato ed è dimostrato, *per tabulas*, attraverso la produzione in atti del certificato di morte e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione, che gli interventori volontari nel giudizio, Parte_2 (coniuge) e Parte_3 (figlia), siano chiamati alla eredità dell'attrice, signora Parte_1 nata a Roma il 18/06/1964, C.F.:

C.F._1 e deceduta nel corso del giudizio. In tal modo essi hanno provato il titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, dai quali desumere il rapporto di coniugio e di parentela con la *de cuius* a norma dell'art. 565 c.c. (v. Cass. sez. L, 30 aprile 2010 n. 10525 secondo cui: *"In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità"*, v. testualmente Cass. Civ., Sez. 2 , Sentenza n. 19254 del 12/07/2024, conforme a Cass. Civ., sez. 2, 6 maggio 2002 n. 6479; v. Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276; Cass. Civ., Sez. 2 ordinanza n. 10519 del 18/04/2024 a mente della quale: *"In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c."* conf. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005; conf. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995 e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973).

Formulando l'azione tesa alla declaratoria dell'usucapione dell'immobile spettante, secondo la prospettazione, anche al comune dante causa, con accessione e continuazione nella relazione col bene immobile *de quo agitur*, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano dimostrato l'accettazione cd. tacita dell'eredità che attiene alla titolarità del diritto ad agire *iure hereditatis* (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018 secondo cui: *"Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che –perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari– non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede"*; v. Cass. Civ. n. 330 del 2024 in cui è richiamata sentenza n. n. 34666/2020 della Suprema Corte secondo cui l'accettazione tacita ricorre

solo se l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al dante causa o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius", conf. Cass. Civ. n. 35466/2020). Da qui la loro legittimazione attiva.

IV. In via pregiudiziale deve osservarsi che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) del quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio con ogni interessato.

La Suprema Corte di Cassazione – v. testualmente Cass. Civ., Ord. Sez. 2, Num. 7490, Anno 2021 – ha sancito che: “...in tema di - giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (cfr. Cass., Sez.2, n. 6163/2006; il principio è stato ribadito rispetto alla fattispecie del condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, cfr. Cass., Sez.2, n. 4624/2013; Cass. Sez.2, n.10745/2019)...”.

La questione del litisconsorzio necessario è, dunque, condizione di ammissibilità della domanda attorea poiché tutti i titolari del diritto di proprietà devono essere chiamati nel giudizio di usucapione dal lato passivo.

Nel caso in cui vi è decesso della parte che ha la legittimazione passiva, bisogna far riferimento agli eredi, anche se non individuati, ma citati impersonalmente e collettivamente mediante notificazione presso il procuratore domiciliatario (v. Cassazione civile, sez. III, sentenza 06/02/2007 n° 2598).

Nel caso di specie, nella parte relativa alla *vocatio in ius* il sig. CP_1 è stato citato in proprio in uno al coniuge, signora Controparte_2 (C.F. C.F._8), nondimeno in calce all'atto introduttivo in riassunzione, redatto in data 14.10.2022, è stata domandata dalla parte costituita a mezzo del patrocinio del procuratore la notifica impersonalmente e collettivamente agli **EREDI della Sig.ra SCORRETTI**

BEATRICE, deceduta in Roma il 10.01.2022, presso l'ultimo indirizzo di residenza in Roma, 00032, via di Pratolungo Casilino n. 152

e la notifica è stata eseguita in data 31.7.2022, nei confronti degli eredi della stessa, impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della defunta.

Invero nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio (come appunto nelle memorie e nei successivi atti di causa) nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, nel complesso dell'atto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15802 del 28/07/2005).

Deve, pertanto, ritenersi che la domanda di usucapione abbia come destinatari anche gli eredi della signora *Controparte_2* e la notificazione collettiva ed impersonale agli eredi della stessa, che determina la pendenza della lite nei confronti di tutti gli eredi, noti ed ignoti, costituisce - **entro l'anno dalla morte** - una facoltà **alternativa, prevista all'art.303 c.p.c.**, alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi determinati ed individuati *nominatim*.

La disposizione di cui all'art. 303 c.p.c. - applicabile sia nei casi di cui all'art. 299 c.p.c. di morte o perdita della capacità giuridica della parte prima della costituzione che in quelli di cui all'art. 300 c.p.c. di morte o perdita della capacità giuridica della parte costituita o della parte contumace - consentendo che la riassunzione possa essere notificata collettivamente agli eredi, entro un anno dalla morte della parte, opera una inversione dell'onere di individuare i legittimati a stare in giudizio, spostandolo dal riassumere agli eredi (Cass. Civ., n.1501 del 1980).

Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato (testualmente, Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019). Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.

Dopo la scadenza del termine annuale, la notificazione ai singoli eredi, nella loro qualità di litisconsorti necessari, è l'unico mezzo per riassumere efficacemente il giudizio (si potrà però anche effettuare eventualmente la notifica nei confronti del curatore dell'eredità o, se manchi, del chiamato in possesso di beni ereditari). Se l'individuazione dell'erede risulterà errata, si determinerà la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata nei confronti dell'erede apparente.

In tale ultimo caso - diverso da quello per cui si procede, in cui la notifica è stata eseguita entro l'anno dalla morte della parte convenuta - operano le seguenti regole ordinarie in tema di onere della prova in ordine alla legittimazione passiva. In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius". Incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede della controparte, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (v. Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 21436 del 30/08/2018, v. Massime precedenti conformi: n. 10525 del 2010).

Nella fattispecie, il caso è diverso come sinora chiarito e l'esame della costituzione in giudizio del convenuto, sig. *Controparte_1* lascia trasparire che questi abbia agito in proprio, quale comproprietario, in uno al coniuge *CP_2* dell'immobile compravenduto, ossia dell'appartamento oggetto di giudizio come accertato a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4675/2021. La circostanza è stata confermata nelle memorie ex art. 183 c.p.c., primo termine, in cui il convenuto, su invito del giudice, ha precisato "...che il sig. *CP_1* è intervenuto nel presente giudizio in proprio, quale comproprietario dell'appartamento oggetto di giudizio come accertato a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4675/2021. Quanto ai figli della Sig.ra *CP_2* e cioè i

Sig.ri i Pt_5 ed Parte_6 essi non hanno ancora accettato l'eredità della madre, ragion per cui non sono qualificabili come eredi della stessa.

Ad ogni buon conto, essendo stati citati impersonalmente nel presente giudizio “gli eredi della Sig.ra CP_2 e non essendosi ad oggi ancora costituiti, si chiede – ove fosse ritenuto necessario in rito – di notificare agli stessi la comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 292 c.p.c...”.

Poiché la domanda attorea è stata proposta sia nei confronti del contitolare del contratto di compravendita dichiarato nullo sia degli Eredi della signora CP_2 con notifica agli stessi in data 31.07.2022 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della stessa entro un anno dalla morte risalente al 10.1.2022, non occorre disporre la rinnovazione dell'atto di citazione agli stessi.

Il sig. Controparte_1, contitolare col coniuge CP_2 del diritto di proprietà sull'immobile compravenduto e dichiarato nullo non ha, peraltro, contestato la sua documentata qualità di coniuge della signora CP_2 e, per tale via, di chiamato all'eredità della stessa e di potenziale successore universale della medesima pro quota.

Per altro vero, il medesimo ha senz'altro, dimostrato l'accettazione tacita dell'eredità della stessa per avere proposto, senza aver esplicitato di aver agito solo pro quota, l'azione di rivendicazione del bene immobile che, in seguito alla declaratoria di nullità dell'atto traslativo del diritto reale di proprietà, è rientrato, prima del decesso del coniuge CP_2 nella disponibilità giuridica della dante causa, contitolare pro quota del detto diritto reale assoluto (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005 secondo cui: *“In tema di “legitimatio ad causam”, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimproato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”, v. massime precedenti N. 5688 del 1988, N. 7125 del 1993, N. 9782 del 1995, N. 11408 del 1998, N. 12753 del 1999).*

Il convenuto Controparte_1 ha, sotto altro profilo, indicato nei figli Pt_5 ed Parte_6 [...] gli altri congiunti chiamati all'eredità e possibili successori universali pro quota nella stessa posizione della signora CP_2

Tale circostanza non è stata contestata dall'attore e dall'interventrice (v. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 14/02/1995 secondo cui: *“In genere i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo così la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili col loro disconoscimento. Tuttavia, nel caso in cui, deceduto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto-*

opposto, si costituiscano volontariamente in prosecuzione soggetti che dichiarino di essere, nella loro qualità di congiunti del "de cuius", i suoi eredi, la mancanza di contestazioni al riguardo dell'opponente assume il particolare valore di una implicita e definitiva ammissione di tale loro qualità (e non di una semplice e irrilevante omissione non preclusiva di successiva eccezione e rilevanza d'ufficio), tenuto presente che solo la validità di tale costituzione, nel difetto di iniziative da parte dell'opponente, vale a prevenire l'acquisto da parte del decreto opposto della sua definitiva esecutività in danno dell'opponente").

Alla luce delle argomentazioni sinora esposte deve, pertanto, dichiararsi la contumacia degli eredi della signora **Controparte_2**

V. Non occorre procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri originari condividenti, **sigg.ri Per_4 e CP_3** non essendo stata proposta una azione di nullità della divisione, essendo stato, invece, domandato di accertare l'usucapione "... *previo accertamento anche ex officio ed incidenter tantum della nullità, per le causali esposte nelle premesse, del suddetto atto pubblico di divisione di comunione, quale atto di provenienza, rogitato dal notaio Persona_2 Rep. 22500/17098 in data 26/11/2009...*", in via incidentale ex art. 34 c.p.c.. La cognizione della questione pregiudiziale è meramente incidentale ed ha, quindi, solo valore strumentale rispetto alla risoluzione della causa e non si esige la partecipazione al processo di tutti i soggetti interessati alla questione stessa (v. Cass. Civ., n. 95 del 7872) e quindi la regolarità del contraddittorio dev'essere valutata con riferimento alla domanda principale ed unica.

VI. Quanto alla questione sottesa alla domanda di nullità dell'atto di divisione ereditaria del bene immobile oggetto della successiva compravendita *de qua agitur*, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25021 del 07/10/2019 hanno sancito il seguente principio di diritto che: *"In forza delle disposizioni eccettuate di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47"*.

A tal fine le S.U. Civili hanno chiarito che la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (denominata *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"*) ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo (art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001); le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità con atti tra vivi dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 d.P.R. cit.). Mentre le sanzioni penali hanno carattere "personale" (art. 27 Cost.) e - come tali - non possono trasmettersi agli eredi di colui che ha commesso l'abuso edilizio, le sanzioni amministrative e quelle civili hanno, invece, carattere "ambulatorio", nel senso che afferiscono al regime giuridico del bene (sono, cioè, *propter rem*) e valgono anche nei confronti degli eredi dell'autore dell'abuso. Tali ultime sanzioni sono state configurate dalla legge in modo da perseguire il duplice scopo di reprimere - con riguardo al futuro - il fenomeno dell'abusivismo edilizio e di sanare - con riguardo al passato - gli abusi edilizi già consumati.

Nella prima direzione temporale, l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che *«Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della*

concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù».

Nella seconda direzione, il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - che *«Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 10settembre 1967, in luogo degli estremi della 7 licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 10settembre 1967»*. Com'è noto, il menzionato art. 17 della legge n. 47 del 1985 è stato abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*) a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo d.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: *"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù"*. Queste Sezioni Unite hanno recentemente statuito che *«La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato»* (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).

Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011). Seppur la nullità scaturisca dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio e non dal carattere illecito dell'edificio in sé (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente; mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), le Sezioni Unite hanno inteso parlare di edifici *"abusivi"* intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi.

Tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/3/2019).

Orbene, dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli *"atti di scioglimento della comunione"* sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche; nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione. La mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato la Suprema Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo *"ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"*, che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non sia applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Tale orientamento è stato rivalutato dalle Sezioni Unite in considerazione della diversa struttura semantica delle due disposizioni normative. Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) si riferisce agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti) per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico (*«trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»*), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti *inter vivos* per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di *«atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»*, prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione *«esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù»*, si rinviene nella disposizione solo con funzione ecceutiva, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).

Hanno affermato, pertanto, che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula *«atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»*; tale espressione, sul piano logico-semantic, risulta comprensiva di tutti gli atti *inter vivos* aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi. Sul piano semantico, dunque, nella detta formula vanno ricompresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti e gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).

Sotto il profilo teleologico, inoltre, avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti. Hanno tutti la medesima disciplina la compravendita o la costituzione di usufrutto, lo scioglimento della comunione, pur se ereditaria, aventi un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo. La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina.

L'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 ha, dunque, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto) sicché deve essere comminata la nullità anche agli atti di scioglimento della comunione di edifici abusivi o loro parti realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967.

Restano fuori dal campo di applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 nonché dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (e prima dell'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985), gli atti *mortis causa* e, tra quelli *inter vivos*, gli atti privi di efficacia traslativa reale (ossia quelli ad effetti meramente obbligatori), gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (espressamente esclusi dalle richiamate disposizioni) e gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali (artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985).

Nondimeno, nella medesima pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ha sancito che nel novero degli atti tra vivi, per i quali l'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come sopra interpretato) commina la sanzione della nullità, possano includersi l'atto di scioglimento della comunione ordinaria e di quella incidentale ereditaria (con ciò superando l'indirizzo preesistente di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; v. Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010 la comunione è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità; per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 355 del 10/1/2011; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1085 del 30/1/1999).

Con ordinanza n. 26564 del 30 settembre 2021 la Suprema Corte ha ribadito i medesimi principi.

Siffatta nullità è, come detto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio dal giudice.

Ciò premesso, a parere del Tribunale, deve ritenersi inammissibile la domanda dell'attore e degli interventori volta all'accertamento incidentale della nullità, ex art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 nonché ex art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 della divisione del bene immobile comune, intercorsa tra Controparte_1 , Controparte_2 ed i sigg.ri Persona_4 ed Controparte_3 (Rep. 22500/17098 del 26.11.2009, v. doc. 3 allegato citazione) e costituente il cd. atto di provenienza, con invalidità derivata della conseguente compravendita avente ad oggetto il medesimo appartamento.

Tale questione, non è stata sollevata in via di azione o di eccezione od in via incidentale, nel giudizio che ha condotto alla declaratoria di nullità dell'atto pubblico di compravendita, per notar Persona_3 , Rep. 100105, dell'immobile abusivo rappresentato da "porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I e precisamente: appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 5, composto di due camere ed accessori, con annessa terrazza a livello, confinante con: vano scala, proprietà CP_1 o aventi causa per due lati. Detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 665, Particella 161, subalterno 511 e Particella 614, Sub 508 graffate -Via Prenestina n. 1204/I, piano 1, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 488,05"

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: *"Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia"* (v. Cass. Civ., sez. I, 28.10.2011, n. 22520), come la questione incidentale attinente all'atto di provenienza *ut supra* esposta.

Pertanto, il giudicato preclude ogni valutazione in ordine alla questione incidentale

A tutto concedere laddove, in tale sede, fosse stata giudicata nulla detta divisione - e così non può ritenersi stante il rilevato giudicato - tale invalidità avrebbe determinato, al di più, la configurazione della compravendita come parzialmente altrui ex art. 1480 c.c..

VI. La domanda di usucapione abbreviata formulata dall'attore e dagli eredi in prosecuzione non è meritevole di accoglimento e dev'essere inesorabilmente respinta.

Ex art. 1159 c.c. “*Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione*”.

L'usucapione abbreviata dell'immobile ha per presupposto il possesso di buona fede e l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire o a costituire il diritto reale sull'immobile, si compie, come nel codice precedente (art. 2137 c.c.), col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione del titolo, conseguito da colui che non è proprietario o contitolare del bene.

Per aversi l'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ. occorre, dunque, la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente “*a non domino*”, e l'oggetto del possesso.

Il concetto di acquisto a *non domino* implica nell'acquirente la qualità di <<terzo>> rispetto al proprietario: dominus e acquirente sono terzi tra loro in quanto non sono parti del rapporto di alienazione di cui si tratta.

L'art. 1159 del c.c., parlando di acquisto in buona fede «*da chi non è proprietario*» dell'immobile, rende chiaro che la disposizione si riferisce all'ipotesi dell'acquisto *a non domino* e non anche all'ipotesi dell'acquisto invalido, viziato, inefficace *a domino* (così risolvendo a una questione a cui dava luogo la formula meno precisa dell'art. 2137 del codice civile del 1865).

L'art. 1159 c.c. non è applicabile quando l'alienazione sia stata compiuta da un *falsus procurator* non essendosi in presenza in tal caso di acquisto a non domino (v. Cass. Civ. n. 1813 del 1983).

Titolo idoneo è in ogni caso l'atto annullabile – finché non viene annullato- ma non anche l'atto nullo (v. Cass. Civ. n.83/3466) perché il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza dell'atto medesimo (conf. Cass. Civ. n. 3255/71).

Nella giurisprudenza di legittimità non è stato ritenuto configurabile l'usucapione decennale, ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., in favore di colui che abbia acquistato un'area di parcheggio vincolata al diritto d'uso riservato “*ex lege*” ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei fabbricati di nuova costruzione, trattandosi di atto nullo per contrarietà a norme imperative e, perciò, di titolo idoneo a trasferire la proprietà, a prescindere dalla sua trascrizione (v. Cassazione, sentenza 9 maggio 2018, n. 11141, sez. II civile; v. in senso conf. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12996 del 24/05/2013).

L'assenza dell'acquisto *a non domino* impedisce la configurabilità dell'istituto invocato, con conseguente rilievo del difetto di legittimazione ad agire di Parte_2 e Parte_3 nelle riferite qualità. Il possesso vantato dagli stessi non sarebbe, in ogni caso, idoneo a fondare la domanda per le ragioni delucidate al capo VIII.

VIII. La domanda attorea di usucapione ordinaria va respinta.

Nelle linee essenziali l'usucapione ordinaria della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni, ininterrotto, pacifico, pubblico, indisturbato, esercitando un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, con l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.

Nel caso in esame a seguito del contratto di compravendita del 12.7.2010 – costituente uno dei modi di acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 922 c.c.- avente ad oggetto l'appartamento facente parte del più ampio fabbricato sito in Roma alla Via Prenestina n. 1204/I (doc. 2 all. citazione), gli acquirenti sono divenuti i comproprietari dell'immobile.

Con la domanda giudiziale volta ad accertare la nullità, ex art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 nonché ex art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, del contratto traslativo della proprietà sull'immobile, i compratori, signori Parte_2 e Parte_1, hanno riconosciuto i venditori, signori Controparte_1 e Controparte_2, quali proprietari dell'appartamento abusivo ed hanno, in tal modo, modificato la loro posizione iniziale inerente all'immobile, connotata dallo *jus possidendi* e dallo *jus possessionis*, in *detentio nomine alieno*.

La posizione del proprietario- possessore viene descritta come *ius possidendi*: il proprietario (od il titolare di un diverso diritto reale su) una res ha “*diritto*” di possederla — giacché quella cosa gli appartiene —, e riceve pertanto tutela dall’ordinamento sia come proprietario, che come possessore.

Il soggetto proprietario dell’immobile che ha una relazione di fatto col bene direttamente o tramite un detentore è comunque tutelato: non in quanto proprietario, ma in quanto possessore (c.d. *ius possessionis*).

Ai sensi dell’art. 1141 e 1164 c.c. chi ha la detenzione non può usucapire la proprietà del bene se il titolo del suo possesso non è mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario.

La precedente relazione dei coniugi **Controparte_6** con l’appartamento non era una detenzione né un possesso *quia possideo*, ma si fondava appunto sull’esistenza dell’atto pubblico notarile, tipico, traslativo della proprietà acquistato dai legittimi proprietari con la compravendita *de qua agitur*.

E’ stato precisato che: “*per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l’"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà*” (v. Cassazione civile sez. VI, 14.5.2021, n. 13153; sez. II, 16.1.2020, n.795; 28.11.2013, n. 26641).

In definitiva l’*interversio possessionis* in detenzione, scaturente dalla notifica ai venditori della domanda di nullità del contratto di compravendita, impedisce, del tutto, la configurabilità e la maturazione dell’usucapione ordinaria.

IX. In via riconvenzionale, il convenuto **Controparte_1** ha domandato:

“...accertare, per quanto occorrer possa l’occupazione sine titolo da parte dei Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2**, dell’appartamento di Via Prenestina n. 1204/I, censito catastalmente al Foglio 665, p.lla 161, sub. 551 e p.lla 614, sub. 508 graffate e, per l’effetto, condannarli a liberare il predetto immobile da persone e cose ed a consegnarlo al sig. **CP_1** ;

- ancora, in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** al pagamento a favore del Sig. **CP_1** a titolo di risarcimento danno da occupazione sine titolo, come sopra meglio specificata, nonché a titolo di indennizzo per l’utilizzazione dell’immobile dal giugno 2010 al luglio 2021, come anche sopra meglio specificato, per una somma totale di € 79.012,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a cui devono aggiungersi le ulteriori somme per la detenzione dell’immobile fino al giorno dell’effettiva liberazione, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU ovvero in via equitativa;

- ancora, sempre in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** al risarcimento del danno a favore del sig. **CP_1** per il deterioramento dell’immobile, quantificato in € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU.

Con vittoria di spese ed onorari di lite”

La domanda riconvenzionale è procedibile ed ammissibile sotto i seguenti profili.

Anzitutto, essa è stata proposta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2023, nei venti giorni rispetto all’udienza fissata in citazione del 16 febbraio 2023, differita con decreto del 10.11.2022 alla data dell’otto marzo 2023. In ordine a ciò la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: secondo cui: “*Il rinvio d’ufficio dell’udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data*

fissata dal giudice istruttore” se emesso prima della scadenza dei termini per la costituzione del convenuto” (v. Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 2299 del 30/01/2017).

Essa, inoltre, è ammissibile poichè inerisce ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile; inoltre, non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 9510 del 27/09/1997).

La domanda riconvenzionale è procedibile per rituale esperimento della mediazione.

Nella memoria ex art. 183 c.p.c., primo termine, il convenuto ha precisato le conclusioni come segue:

“... accertare, per quanto occorrer possa l'occupazione sine titolo da parte del Sig. Pt_2 e della Sig.ra Pt_2 , anche quali eredi della Sig.ra Parte_1 , dell'appartamento di Via Prenestina n. 1204/I, censito catastalmente al Foglio 665, p.lla 161, sub. 551 e p.lla 614, sub. 508 graffate e, per l'effetto, condannarli a liberare il predetto immobile da persone e cose ed a consegnarlo al sig. CP_1 ;

- ancora, in via riconvenzionale, condannare il Sig. Pt_2 e la Sig.ra Pt_2 , anche quali eredi della Sig.ra Parte_1 , al pagamento a favore del Sig. CP_1 a titolo di risarcimento danno da occupazione sine titolo, come sopra meglio specificata, nonché a titolo di indennizzo per l'utilizzazione dell'immobile dal giugno 2010 al luglio 2021, come anche sopra meglio specificato, per una somma totale di €. 79.012,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a cui devono aggiungersi le ulteriori somme per la detenzione dell'immobile fino al giorno dell'effettiva liberazione, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno calcolato a far data dal 3.7.2014, data di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione per nullità della compravendita, momento in cui è certamente cessata l'occupazione in buona fede dell'immobile, ovvero ancora in via graduata a far data dalla pubblicazione o passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n. 4675/2021 o, ancora in via subordinata, la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU ovvero in via equitativa;

- ancora, sempre in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri Parte_1 e Pt_2 al risarcimento del danno a favore del sig. CP_1 per il deterioramento dell'immobile, quantificato in €. 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, anche mediante apposita CTU.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.”

Siffatte specificazioni della domanda riconvenzionale sono ammissibili perché non ne alterano, in definitiva, la *causa petendi* ed il *petitum*.

Avuto riguardo al merito, la domanda riconvenzionale è fondata per quanto di ragione.

Dal rilievo della nullità del contratto sorge l'obbligo restitutorio del versamento del prezzo (pari ad euro 220.000,00 da parte del Sig. CP_1 a favore dei Sigg.ri Parte_1 e Pt_2 , somma quest'ultima peraltro già oggetto di precetto) nonché anche d'ufficio l'obbligo di restituzione dell'immobile ai contitolari (v. al riguardo Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7651 del 13/04/2005; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011, secondo cui: *“Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale”*).

Come statuito dalle S.U. con la sentenza n. 14828 del 2012, **in tema di rilevanza d'ufficio di una causa di nullità del contratto, del quale parte attrice abbia chiesto la risoluzione, una delle conseguenze dell'accertamento della nullità del negozio è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione**

rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria (nella specie il locatore aveva insistito per il rilascio dell'immobile sia pure come conseguenza della risoluzione). Infatti qualora venga acclarata la mancanza di una "*causa adquirendi*" -tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente- l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. **Ne consegue che ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o, come nel caso in esame, per altra causa e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato** (v. motivazione della sentenza citata delle S.U. n. 14828 del 2012, secondo cui: *"...altro esito del rilievo d'ufficio della nullità e del relativo accertamento è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria. Questa conseguenza si verifica senz'altro in ipotesi di modifica della domanda con richiesta di declaratoria della nullità. Altrettanto avverrà però in ipotesi di rigetto - fondato sulla nullità contrattuale rilevata d'ufficio - della domanda di risoluzione, alla quale sia associata, anche originariamente, la richiesta di condanna alle restituzioni. Il rilievo della nullità fa venir meno la "causa adquirendi" e la richiesta di restituzione del bene consegnato in esecuzione del contratto, che era già stata formulata con la pretesa iniziale, sarà accolta sulla base di questo presupposto, senza bisogno di espressa dichiarazione della nullità. Va infatti confermato che qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. 2956/11 cit.) inoltre cfr. Cass. 9052/10; 1252/00; e anche 21096/05; 5624/09)..."*.

V. altresì Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2742 del 02/02/2017 secondo cui: *"Nella ipotesi di azione di sfratto per morosità, la declaratoria di nullità del contratto per mancata registrazione, con contestuale condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, non implica un vizio di ultrapetizione, né la violazione del diritto di difesa dell'intimato."* Massime precedenti Vedi: N. 1368 del 2016; Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015).

In ordine alla natura, appare opportuno premettere che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa, e di non averne più il possesso, sottrattogli contro la sua volontà sicché agisce contro chiunque di fatto la posseda e la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, che è, pertanto, tenuto a provare, sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa; invece, l'azione di restituzione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita od in base al quale la deteneva e tende solo alla riconsegna della cosa stessa, sicché l'attore può limitarsi a fornire la dimostrazione dell'avvenuta consegna della cosa in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. Cass. 19.2.2002 n. 2392 conf. 24-2-2000, n. 2092).

Pertanto, tali azioni essendo entrambe dirette allo stesso risultato pratico del recupero del possesso del bene possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa, ovvero che, essendo stata promossa espressamente soltanto una di esse, questa possa trasformarsi in corso di giudizio nell'altra in relazione alle eccezioni del convenuto (cfr., giurisprudenza costante sin da Cass. 28-1-85, n. 439).

Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con la recentissima sentenza n. 7305 del 28.3.2014 hanno affermato che a composizione di contrasto – enunciano i seguenti principi: (a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale; (b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale *inter partes*, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la *probatio diabolica*.

V. pure S.C. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013 secondo cui: *“La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile”*.

Nella specie, tenendo conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (comproprietà dell'immobile oggetto di causa da parte dello CP_1) nonché del provvedimento giurisdizionale richiesto in concreto (condannare le controparti alla liberazione dell'immobile occupato sine titolo, con correlativa condanna al risarcimento del danno), deve ritenersi che la parte convenuta costituita abbia proposto, inequivocabilmente, l'azione personale di restituzione volta a conseguire il possesso della cosa da parte degli occupanti sine titolo (negli atti di causa è stato ammesso dagli interessati che [...] Pt_2 e Parte_3 siano, tuttora, nell'effettivo godimento dell'immobile).

Alle pronunce allegate in atti esitate in cosa giudicata e alle valutazioni compiute nel presente giudizio consegue, pertanto, la condanna degli ex comproprietari, ora occupanti di fatto alla restituzione immediata, in favore del comproprietario istante, dell'immobile compravenduto in virtù di atto pubblico dichiarato nullo, libero di persone e sgombro di cose.

I signori Pt_2 vanno, altresì condannati al versamento, a titolo di indennità di occupazione sine titolo, di **euro 9.922,50** rivalutate all'attualità dal giugno 2021 – **epoca in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte d'Appello di Roma – fino al febbraio 2023 - momento del deposito della comparsa con domanda riconvenzionale-** considerando il valore locativo di una abitazione (di tipo economico) di circa 70 mq, ricadente in zona E22-Suburbana e parametrando il danno figurativo al valore locativo ^{Contro} el bene immobile. Il tutto oltre interessi dalla domanda al saggio medio del 2,8%.

Quanto all'istanza risarcitoria – tale dovendosi qualificare quella rivolta a conseguire l'indennità per l'occupazione sine titolo (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/12/2016 n° 25503) - i parametri di riferimento sono rappresentati dall'arricchimento di cui colui che gode dell'immobile e dal correlativo impoverimento del proprietario per la perdita, durante l'occupazione da parte di terzi, della possibilità di godere dell'immobile in via diretta od indiretta costituendo sullo stesso un diritto reale o personale di godimento.

Oltre a ciò l'attore in proprio e quale erede nonché l'erede della CP_2 vanno condannati in solido al pagamento in favore del contitolare della somma di euro 522,23 da marzo 2023 all'effettivo rilascio, stante la richiesta effettiva, oltre interessi al saggio legale.

Al riguardo va precisato che solo a date condizioni sono ammesse le pronunce condizionali o anche dette cd. condanne in futuro, aventi ad oggetto l'accertamento di un diritto, la cui fattispecie non si è ancora completamente integrata e che, come tale, non può ritenersi esigibile.

Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Infatti con dette sentenze non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto. Si osserva — peraltro — che una tale pronuncia in tanto è ammissibile in quanto la “circostanza” dedotta in condizione non richieda altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verifica o meno della circostanza stessa.

V. sul punto, di recente Cass. Civ., sezione III, sent. n. 19895 del 6/10/2015 secondo cui: *“Questa Corte ha più volte ammesso la possibilità di pronunciare sentenze di condanna condizionali, ma a patto che l'elemento condizionante sia certo ed inequivoco. La sentenza condizionale infatti deve essere tale da “non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata” (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010, Rv. 615532). Non è, per contro, consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009, Rv. 608810; Sez. 3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008, Rv. 603837; Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004, Rv. 577467)”*.

Per il periodo pregresso al passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata accertata la nullità della compravendita, l'indennizzo può essere determinato in € 69.090,00, determinata sulla base del valore locativo mensile dell'immobile ricavato dai valori OMI, dal luglio 2010 al giugno 2021, oltre interessi al saggio legale medio.

Nondimeno, a parere del Tribunale, non si può non tenere conto del fatto che anche i venditori abbiano contribuito consapevolmente ad instaurare con i compratori un rapporto nullo: non risulta infatti, che i primi si siano mai attivati per la regolarizzazione dell'atto e dell'immobile, nel periodo di permanenza dei compratori nell'appartamento di loro proprietà.

Riconoscere integralmente ai comproprietari quanto gli avrebbe fruttato un contratto locativo regolarmente registrato significherebbe deresponsabilizzare i primi ed avvalorare la stipula di contratti nulli (oltre che fiscalmente non tassabili).

Si ritiene, pertanto, che nella liquidazione del danno patito dai titolari per la abusiva occupazione possa farsi applicazione dell'art.1227 c.c. che in presenza di un “fatto colposo del creditore”, che ha concorso a cagionare il danno (consegna dell'immobile senza la previa o la successiva stipula di un contratto valido), consente di diminuire il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Argomenti a sostegno possono trarsi anche dall'art.13 comma 6 della legge n.431/98 (come novellato dall'art.1 comma 59 della L. n. 208/2015) che, nel caso di nullità di un contratto di locazione per omessa registrazione, prevede che il canone che il giudice determina (su istanza del conduttore) non possa “eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'art.2” della legge n.431/98, ovvero quello applicabile ai contratti a canone c.d. concordato.

La riduzione per il concorso del creditore appare equa nella misura del 30% (tale in genere è il gap tra le locazioni a canone libero e quelle a canone concordato) da computarsi rispetto al canone OMI individuato di euro 69.090,00 mensili.

In definitiva il sig. **Parte_2** in proprio e nella qualità e la sig.ra **Parte_3** nella qualità di erede di **Parte_1** sono tenuti a corrispondere al sig. **CP_1** nella qualità di comproprietario dell'immobile, in solido, a titolo di indennità di occupazione, l'importo di **€. 9.922,50** rivalutato all'attualità dal giugno 2021 fino al febbraio 2023, oltre interessi dalla domanda al saggio legale medio del 2,8%; oltre ad **€. 522,23** rivalutati alla attualità mensili dal marzo 2023 all'effettivo rilascio, stante la richiesta effettiva, oltre interessi al saggio legale medio del 2,8%, nonché al versamento di **€. 48.363,00 rivalutata all'attualità**, dal 2010 al maggio 2021, oltre interessi al saggio legale medio del 0,8% a far tempo dalla domanda al soddisfo.

La presente pronuncia resa in favore del singolo condebitore istante (nella qualità di comproprietario, *iure proprio*, al 50% dell'immobile) per l'intero, lascia inalterati i diritti/doveri tra eventuali condebitori nel rapporto interno.

X. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (da euro 56.000,00 – euro 260.000,00) e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del *quid disputatum* mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del *decisum*), con applicazione del tariffario D.M. n. 55 del 2014 e succ. modificazioni.

Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. il giudice d'ufficio ritiene di dover condannare la parte attorea soccombente, in favore della parte convenuta costituita, al pagamento di una somma equitativamente determinata che individua in euro 1.000,00.

Nel rapporto con gli eredi della signora **CP_2** collettivamente ed impersonalmente, le spese sono irripetibili (*"Poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato". Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza 13491 del 13.06.2014*).

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90.

Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) dichiara, per le ragioni id cui in motivazione, la contumacia degli eredi della signora **CP_2** [...] (c.f. **C.F. 8**);
- 2) dichiara, per le ragioni id cui in motivazione, l'inammissibilità della domanda incidentale formulata dall'attore e dagli interventori;
- 3) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di usucapione abbreviata ed ordinaria;
- 4) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di restituzione, come riqualificata e, per l'effetto, condanna il sig. **Parte_2** in proprio e nella qualità di erede della signora **Parte_1** e la sig.ra **Parte_3** nella qualità di erede di **Parte_1** in solido all'immediato rilascio, in favore del convenuto, **Controparte_1**, nella qualità di comproprietario in proprio nella misura del

50%, dell'appartamento interno n. 5 di cui all'atto pubblico di compravendita per notar *Persona_3*, Rep. 100105, così ivi descritto: *"porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, via Prenestina n. 1204/I e precisamente: appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 5, composto di due camere ed accessori, con annessa terrazza a livello, confinante con: vano scala, proprietà Scancelli o aventi causa per due lati. Detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 665, Particella 161, subalterno 511 e Particella 614, Sub 508 graffate -Via Prenestina n. 1204/I, piano 1, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 488,05"*, libero da persone e sgombero da cose;

5) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di restituzione, come riqualficata, e, per l'effetto, condanna il sig. *Parte_2* in proprio e nella qualità di erede della signora *Parte_1* [...] e la sig.ra *Parte_3* nella qualità di erede di *Parte_1* in solido al pagamento in favore del convenuto, *Controparte_1*, nella qualità di comproprietario in proprio, a titolo di indennità di occupazione, dell'importo di **€. 9.922,50** rivalutato all'attualità dal giugno 2021 fino al febbraio 2023, oltre interessi dalla domanda al saggio legale medio del 2,8%; oltre ad **€. 522,23** mensili, rivalutati alla attualità, dal marzo 2023 all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale medio del 2,8%, nonché al versamento di **€. 48.363,00 rivalutata all'attualità**, dal 2010 al maggio 2021, oltre interessi al saggio legale medio del 0,8% a far tempo dalla domanda al soddisfo.

6) condanna il sig. *Parte_2* in proprio e nella qualità di erede della signora *Parte_1* [...] e la sig.ra *Parte_3* nella qualità di erede di *Parte_1* in solido al pagamento in favore del convenuto, *Controparte_1*, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge, oltre euro 1.000, ex artt. 91 e 96 comma 3 c.p.c.

7) spese irripetibili nei confronti degli eredi di *Controparte_2* contumaci.

Così deciso in Roma, il 10/10/2024

Il Giudice Unico
(dott. ssa Maria Flora Febbraro)